

1502087-45.2021.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... de que o réu, de fato, praticava tráfico.

Anoto, ainda, que o acusado já se viu processar por tráfico em outra oportunidade (sendo desclassificada a conduta - fl. 46), o que também é indicativo de seu envolvimento em tais atividades. Também importante consignar que o réu negou ser usuário de crack, sendo este o entorpecente apreendido no local. Outro fator a se ponderar é a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502087-45.2021.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502087-45.2021.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245933/2021 - DISE-

DEL.SEC.ANDRADINA, 20149081 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 37/21/118 - DISE-

DEL.SEC.ANDRADINA, 2245933 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBSON DA SILVA LADEIA

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra ROBSON DA SILVA LADEIA imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 05h05min, na Rua Presidente Dutra, nº 535, Jardim Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, vulgo "Robinho", qualificado às fls.10, 18 e 40 dos presentes autos, tinha em depósito, para fins de tráfico, 10 porções de "crack", com peso aproximado de 46,05g (cf. auto de constatação provisório de fls.38/39), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2021, em decisão de fl.155.. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.85/86.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF em fl. 1/2; boletim de ocorrência em fls. 3/6, termo de depoimento em fls.7/9, termo interrogatório APF em fl.10, fotografias em fls. 23/25 e 41 , autos de exibição e apreensão de fls.12/13, laudos periciais de fls.182/184), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido: Fernando Jacinto Richard Quintas, policial militar, disse que foram cumprir mandado de busca na residência do réu e que, por se tratar de residência bastante fechada, utilizaram uma escada para subir no telhado. Visualizaram o acusado saindo da residência com uma sacola, a qual arremessou no telhado da residência vizinha. Como o acusado demorou para abrir o portão, a equipe que estava no solo teve de forçá-lo para ingressar no local. O réu falou que havia droga e dinheiro na sacola que ele jogou no telhado. No total localizaram 8 porções de crack e diversas notas espalhadas pelo telhado. O réu disse que estava desempregado e havia comprado R\$ 1.000 em crack na cidade de Castilho para revender em Andradina. Na casa não localizaram nada. O dia estava clareando no momento do cumprimento do mandado, que se deu por volta das 6 horas.

Adriano Bertuci Aguilera, policial militar, basicamente confirmou a versão de seu colega.

A testemunha de defesa Fernando Henrique Matias da Silva reportou que o réu lhe prestava serviços à época dos fatos, sendo pessoa trabalhadora e diligente. Não é do seu conhecimento ser o réu usuário de drogas.

Interrogado, o réu negou os fatos. Disse que estava dormindo e que foi acordado com um policial apontando uma arma para seu rosto. Negou que tivesse drogas na casa ou mesmo ter arremessado as drogas no telhado.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese tem-se apreensão de relevante quantidade de crack, mormente a se considerar as dimensões da Comarca de Andradina. Apenas a título de argumentação, anote-se que a pedra de crack para consumo imediato tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017). Ou seja, os 46,05 gramas de crack seriam suficientes para até 230 doses do entorpecente.

Ademais, a diligência foi realizada após diligências prévias, em cumprimento a mandado de busca, confirmados os indicativos de que o réu, de fato, praticava tráfico.

Anoto, ainda, que o acusado já se viu processar por tráfico em outra oportunidade (sendo desclassificada a conduta - fl. 46), o que também é indicativo de seu envolvimento em tais atividades. Também importante consignar que o réu negou ser usuário de crack, sendo este o entorpecente apreendido no local. Outro fator a se ponderar é a apreensão de 4 aparelhos celulares no local, dispositivo comumente utilizado por traficantes para suas atividades, não sendo razoável que uma pessoa simples, mero trabalhador com poucos recursos, tenha essa quantidade de telefones em sua posse.

No mais, totalmente fantasiosa a versão do réu de que a droga não estava na residência e que estava dormindo quando da chegada dos policiais. Estes prestaram versão bastante detalhada no sentido de que tiveram de utilizar uma escada em virtude das características da residência do réu, bastante fechada.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Quanto ao horário e condições visuais, anoto que um dos policiais relatou que estava clareando, e o outro falou que ainda estava escuro. Todavia, isto não significa que a versão dos policiais deve ser desacreditada, pois o fato de ainda não estar totalmente claro não significa que os policiais não conseguiriam ver o réu saindo da residência e arremessando a sacola para tentar se livrar das drogas. Quanto ao ingresso na residência, é de se observar que se trata de crime permanente, autorizando que os agentes da força policial possam adentrar ao domicílio, conforme artigo 5º, inciso XI, in fine, da Constituição Federal e artigo 150, § 3º, inciso II, do Código Penal. Nessa linha é a jurisprudência: "por ser permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protraí no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do infrator, sendo possível, portanto, em tal hipótese, o ingresso da polícia na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade inscrita no art. 5º, inciso XI, da CF, a afastar a inviolabilidade do domicílio" (HC nº 208.957/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06/12/2011).

Reporto-me, ainda, à decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no RExt 603.616, no qual fixou-se a seguinte tese com repercussão geral "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". Na hipótese, havia mandado de busca, que foi cumprido logo ao amanhecer (sendo subjetiva a especificidade de estar o dia "clareando" ou ainda "escuro"). Assim, totalmente legítima a ação, inclusive quanto ao fato dos policiais utilizarem uma escada, o que fora feito, evidentemente, para preservar a efetividade da diligência.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico é procedente.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao

contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça). Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais".

E ainda (AgRg no REsp 1704633 / T0 - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, em razão da natureza da droga (crack), entendo pela exasperação da pena-base em 1/8, pelo critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito). A droga que o réu tinha em seu poder para fins de tráfico é de alto poder viciante e destrutivo, que atualmente acarreta grave problema social em nossa sociedade. Ademais, a quantidade apreendida é relevante para os padrões da Comarca. Não seria isonômico aplicar àquele que trafica substância de menor nocividade o mesmo patamar para o traficante de drogas mais "pesadas". Cabe a exasperação, portanto, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Nesse passo, estabeleço a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado é reincidente (fl. 46), o que demanda a exasperação em mais 1/6, pelo mesmo modo de cálculo, o que conduz a reprimenda a 7 anos e 11 meses e 791 dias-multa.

Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, por conta dos antecedentes criminais do acusado.

Sendo assim, a pena fica em 7 anos e 11 meses de reclusão e 791 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime, quantidade de pena e reincidência deve ser o fechado. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO ROBSON DA SILVA LADEIA, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 791 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

O réu respondeu ao processo preso e foi condenado a pena relativamente alta.

Formada sua culpabilidade em juízo de certeza, não vislumbro razões para que seja posto em liberdade. Entendo assim, que permanecem os motivos para a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento.

À mingua de cálculo sobre o lapso de pena cumprida e dados sobre o comportamento do acusado, eventual juízo sobre a progressão de pena deve ser efetuado pelo juízo das execuções.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas, servindo a presente por ofício.

Com relação aos bens e valores apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Andradina, 18 de janeiro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)